

**RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK**

**VOORZITTER VAN DE XIIe KAMER**

**A R R E S T**

**nr. 248.824 van 3 november 2020  
in de zaak A. 231.940/XII-8965**

In zake: de NV KING BELGIUM  
bijgestaan en vertegenwoordigd door  
advocaten Evi Degroodt en Kris Lemmens  
kantoor houdend te 2000 Antwerpen  
De Burburestraat 6-8/5  
bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

de STAD GENT  
bijgestaan en vertegenwoordigd door  
advocaten Patrick Devers en John Devers  
kantoor houdend te 9000 Gent  
Kouter 71-72  
bij wie woonplaats wordt gekozen

---

*I. Voorwerp van de vordering*

1. De vordering, ingesteld op 5 oktober 2020, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van:

“- de beslissing van het College van burgemeester en schepenen van de stad Gent van 10 september 2020 waarmee wordt beslist om de offerte van NV King Belgium voor de raamovereenkomst voor het leveren van duurzame en standaard schoonmaakproducten, schoonmaakmiddelen en sanitaire behoeften (SLS/2019/044-ID4706) substantieel onregelmatig te verklaren en niet te behouden voor verdere evaluatie, en;  
- de beslissing van het College van burgemeester en schepenen van de stad Gent van 10 september 2020 waarmee wordt beslist de offerte van BVBA De Bruycker S. – Van Lierop M. regelmatig te verklaren en om de raamovereenkomst voor het leveren van duurzame en standaard schoonmaakproducten, schoonmaakmiddelen en sanitaire behoeften (SLS/2019/044-ID4706) te gunnen aan BVBA De Bruycker S. – Van Lierop M., en;

- de impliciete beslissing van het College van burgemeester en schepenen van de stad Gent van 10 september 2020 waarmee wordt beslist om de raamovereenkomst voor het leveren van duurzame en standaard schoonmaakproducten, schoonmaakmiddelen en sanitaire benodigdheden (SLS/2019/044-ID4706) niet te gunnen aan NV King Belgium.”

## *II. Verloop van de rechtspleging*

2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 22 oktober 2020, om 11.00 uur.

Staatsraad Johan Bovin heeft verslag uitgebracht.

Advocaat Evi Degroodt, die verschijnt voor de verzoekende partij, en advocaat John Devers, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

Eerste auditeur Ines Martens heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

## *III. Feiten*

3.1. De stad Gent schrijft een overheidsopdracht uit voor leveringen met als voorwerp: “Raamovereenkomst voor het leveren van duurzame en standaard schoonmaakproducten, schoonmaakmiddelen en sanitaire benodigdheden”, waarbij zij optreedt als aankoopcentrale.

De opdracht wordt gegund door middel van een openbare procedure. Het betreft een opdracht tegen prijslijst.

3.2. De opdracht is onderworpen aan het bestek “Raamovereenkomst voor het leveren van duurzame en standaard schoonmaakproducten, schoonmaakmiddelen en sanitaire benodigdheden” – SLS/2019/044-ID4706.

Met betrekking tot de gunningscriteria wordt in het bestek bepaald:

“ I.10 Gunningscriteria

Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht:

| Nr.                             | Beschrijving      | Gewicht |
|---------------------------------|-------------------|---------|
| 1                               | Prijs             | 70      |
| 1.1                             | Inventaris        | 45      |
| 1.2                             | Korting catalogus | 25      |
| 2                               | Duurzaamheid      | 30      |
| 2.1                             | Project           | 20      |
| 2.2                             | Sociale economie  | 10      |
| Totaal gewicht gunningscriteria |                   | 100     |

[...]

Toelichting bij de gunningscriteria:

1. Prijs: 70 punten

1.1. Inventaris: 45 punten

[...]

Opgelet! Indien de offerte voor meer dan 10% van de artikelen opgenomen in de inventaris geen conform voorstel bevat, wordt de offerte beschouwd als niet regelmatig en voor verder onderzoek uitgesloten.

Om de geldigheid van de offertes te bewaren, zal de aanbesteder de formule van leemtes toepassen voor de posten waarvoor de inschrijver eventueel geen conform artikel heeft ingediend en waarvoor dit toegestaan kan worden. De formule van leemtes baseert zich op de gemiddelde artikelprijs opgegeven door de overige inschrijvers die wel een conform artikel hebben aangeboden. Het prijsvergelijk zal gebeuren op basis van de totale prijs van alle artikelen, dus ook van deze eventueel berekend via de formule van leemtes.

1.2. Korting catalogus: 25 punten

Naast de artikelen opgenomen in de inventaris, dient de inschrijver een supplementair aanbod van minstens 1.000 artikelen binnen het gamma van artikelen die het voorwerp van deze opdracht uitmaken aan te kunnen bieden.

De inschrijver dient een kortingspercentage van minimaal 5% te geven op alle bijkomende artikelen die besteld worden naast de artikelen die reeds opgenomen zijn in de inventaris. Het aangeboden kortingspercentage mag één algemeen percentage zijn dat van toepassing is op alle artikelen, maar mag ook één percentage per productgroep of merk zijn. Het/de aangeboden

kortingspercentage(s) is/zijn geldig op alle artikelen die naast de inventaris besteld worden en voorwerp uitmaken van deze opdracht.

De inschrijver dient een (tijdelijke) login op zijn webshop aan te maken, gelinkt aan het e-mailadres [aline.decokere@stad.gent](mailto:aline.decokere@stad.gent). Via deze login moet de aanbesteder in staat zijn om alle artikelen die het voorwerp uitmaken van deze opdracht te raadplegen. De volgende gegevens moeten daarbij minimaal zichtbaar zijn:

- omschrijving,
- merk,
- foto,
- verpakkingseenheid/inhoud,
- artikelnummer leverancier,
- bruto eenheidsprijs excl. btw (dus zonder korting).

De inschrijvers dienen de nodige gegevens voor de login en het/de kortingspercentage(s) in te vullen in het daartoe bestemde formulier in bijlage E.

De aanbesteder legt vooraf een lijst van 50 bijkomende courant afgenomen artikelen vast. De aanbesteder geeft deze lijst vooraf niet mee aan de inschrijvers om speculatie van de inschrijvers te vermijden. De totale nettoprijs van de vergelijkbare artikelen uit die lijst die in het aanbod van elke inschrijver voorkomen, zal beoordeeld worden op hetzelfde moment. De nettoprijs per artikel wordt bekomen door van de brutoprijs excl. btw (die zichtbaar moet zijn via de login op de website) de korting (die ingevuld wordt in bijlage E) af te trekken.

Het gunningscriterium 'korting catalogus' zal als volgt beoordeeld worden:  $\text{Score offerte} = (\text{laagste totale eenheidsprijs van de vergelijkbare artikelen van alle inschrijvers} / \text{totale eenheidsprijzen van de vergelijkbare artikelen van de inschrijver}) \times \text{gewicht van het criterium korting bijkomende artikelen.}$

3.3. De opdracht wordt op 27 maart 2020 bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen en in het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie.

3.4. De opening van de offertes vindt plaats op 15 juni 2020. Er worden vier offertes ingediend, waaronder de offerte van de verzoekende partij en van de gekozen inschrijver.

3.5. Op 25 augustus 2020 wordt een gunningsverslag opgesteld.

Onder de titel "Evaluatie en verbetering van gemelde leemten/ontbrekende prijzen" wordt onder meer vermeld:

"[...]"

Aangezien geen enkele inschrijver voor post 54 een conform artikel heeft aangeboden, kan de formule van leemtes niet toegepast worden en wordt post 54 geschrapt voor alle inschrijvers. De door de aanbesteder berekende totaalbedragen zijn:

[...]

Voor de inschrijver De Bruycker S.-Van Lierop M. bvba wordt de formule van leemtes toegepast:

Er werden vijf artikelen aangeboden die niet conform zijn (zie punt 6. ‘regelmaticheid van de offerte’). Bijgevolg wordt hiervoor de formule van leemtes toegepast, die zich baseert op de gemiddelde artikelprijs opgegeven voor de overige inschrijvers die wel een conform artikel hebben aangeboden. Bijgevolg worden de volgende nieuwe eenheidsprijzen exclusief btw bekomen:

- Post 48: 1,480000 EUR,
- Post 49: 0,473333 EUR,
- Post 54: geschrapt,
- Post 59: 0,125000 EUR,
- Post 61: 0,320000 EUR.

[...].”

Onder de titel “Regelmaticheid van de offertes” wordt voorts vermeld:

“6.1 Volgende punten van regelmaticheid werden onderzocht

[...]

G. Is de offerte voor het overige inhoudelijk conform met de opdrachtdocumenten en volledig regelmatig of bevat zij onregelmatigheden? Zijn die onregelmatigheden van substantiële of niet-substantiële aard?

| Nr. | Inschrijver                              | A  | B  | C  | D  | E  | F  | G   | H  |
|-----|------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|----|
| 1   | Boma NV                                  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NOK | OK |
| 2   | De Bruycker S. -<br>Van Lierop M<br>BVBA | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK  | OK |
| 3   | King Belgium NV                          | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NOK | OK |
| 4   | Verpa Benelux NV                         | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NOK | OK |

Toelichting bij de tabel:

[...]

(6) De inschrijver De Bruycker S. – Van Lierop M. BVBA heeft voor de posten 43, 62, 66, 67 en 68 uit de inventaris geen artikelnummers opgenomen in de inventaris, waardoor de aanbesteder niet kon controleren of de voorgestelde artikelen voldoen aan de gestelde vereisten. Op 16/07/2020 heeft de aanbesteder hieromtrent meer informatie gevraagd. Op 31/07/2020 heeft de inschrijver per e-mail de nodige informatie en correcte documenten bezorgd. Dit betreft geen substantiële onregelmatigheid.

(6) De inschrijver De Bruycker S. – Van Lierop M. BVBA heeft voor de volgende posten een artikel opgenomen dat niet conform is:

- Voor post 48 uit de inventaris, ‘handveger, kunststof’, werd een product aangeboden dat deels vervaardigd is uit PVC. Het bestek vereiste dat er geen producten die vervaardigd zijn uit PVC aangeboden mogen worden, tenzij het gevraagde product niet beschikbaar is in een ander materiaal. Uit de voorstellen van de andere inschrijvers blijken er wel degelijk producten te bestaan die conform zijn en niet vervaardigd zijn uit PVC. Bijgevolg is het voorstel voor post 48 niet conform.
- Voor post 49 uit de inventaris, ‘huishoudspons’, werd een product aangeboden waarvan de breedte groter is dan wat maximaal toegelaten werd. Bijgevolg is het voorstel voor post 49 niet conform.
- Voor post 54 uit de inventaris, ‘microvezeldoek, rood, 40 x 40 cm’, werd een product in een andere dan de vereiste kleur aangeboden. Bijgevolg is het voorstel voor post 54 niet conform.
- Voor post 59 uit de inventaris, ‘schuurspons, geel/groen, met handgreep’, werd een product in een andere dan de vereiste kleuren aangeboden. Bijgevolg is het voorstel voor post 59 niet conform.
- Voor post 61 uit de inventaris, ‘vaatdoek, wit’, werd een product aangeboden waarvan de afmetingen groter zijn dan wat maximaal toegelaten werd. Bijgevolg is het voorstel voor post 61 niet conform.

Indien de offerte voor meer dan 10% van de artikelen opgenomen in de inventaris geen conform voorstel bevat, wordt de offerte beschouwd als niet regelmatig en voor verder onderzoek uitgesloten. In totaal waren er 75 posten waarvoor er een artikel diende aangeboden te worden. Meer concreet wordt de offerte dus als niet regelmatig beschouwd van zodra er acht artikelen niet conform zijn. In totaal werden er door de inschrijver De Bruycker S. – Van Lierop M. BVBA vijf artikelen aangeboden die niet conform zijn. Bijgevolg blijft de offerte behouden voor verdere evaluatie en betreft dit geen substantiële onregelmatigheid. Zoals vermeld werd in het bestek, wordt de formule van leemtes toegepast voor de posten waarvoor de inschrijver geen conform artikel heeft ingediend (zie punt 5.3 ‘evaluatie en verbetering van gemelde leemten/ontbrekende prijzen’).

[...]

(10) De inschrijver King Belgium NV heeft voor de volgende posten een artikel opgenomen dat niet conform is:

- Voor post 41 uit de inventaris, ‘afwasborstel, kunststof’, werd een product aangeboden dat deels vervaardigd is uit PVC. Het bestek vereiste dat er geen producten die vervaardigd zijn uit PVC aangeboden mogen worden, tenzij het gevraagde product niet beschikbaar is op de markt in een ander materiaal. Uit de voorstellen van de andere inschrijvers blijken er wel degelijk producten te bestaan die conform zijn en niet vervaardigd zijn uit PVC. Bijgevolg is het voorstel voor post 41 niet conform.
- Voor post 54 uit de inventaris, ‘microvezeldoek, rood, 40 x 40 cm’, werd een product aangeboden in een andere dan de vereiste kleur. Bijgevolg is het voorstel voor post 54 niet conform.

- Voor post 61 uit de inventaris, 'vaatdoek, wit', werd een product aangeboden waarvan de afmetingen groter zijn dan wat maximaal toegelaten werd. Bijgevolg is het voorstel voor post 61 niet conform.
- Voor post 62 uit de inventaris, 'vuilzak, 44 x 60 cm, min. 10 µm, wit', werd een product aangeboden in een andere dan de vereiste kleur. Bijgevolg is het voorstel voor post 62 niet conform.
- Voor post 63 uit de inventaris, 'vuilzak, 50 x 55 cm, min. 25 µm', werd een product aangeboden waarvan de afmetingen groter zijn dan wat maximaal toegelaten werd. Bijgevolg is het voorstel voor post 63 niet conform.
- Voor post 64 uit de inventaris, 'vuilzak, 70 x 110 cm, min. 25 µm, wit', werd een product aangeboden in een andere dan de vereiste kleur. Bijgevolg is het voorstel voor post 64 niet conform.
- Voor post 66 uit de inventaris, 'vuilzak, 80 x 110 cm, min. 30 µm, zwart', werd een product aangeboden in een andere dan de vereiste kleur. Bijgevolg is het voorstel voor post 66 niet conform.
- Voor post 68 uit de inventaris, 'vuilzak, pedaalemmer, 60 x 60 cm, min. 15 µm, wit', werd een product aangeboden in een andere dan de vereiste kleur. Bijgevolg is het voorstel voor post 68 niet conform.
- Voor post 82 uit de inventaris, 'toiletborstel, kunststof, met randreiniger en houder, wit', werd een product aangeboden dat deels vervaardigd is uit PVC. Het bestek vereiste dat er geen producten die vervaardigd zijn uit PVC aangeboden mogen worden, tenzij het gevraagde product niet beschikbaar is op de markt in een ander materiaal. Uit de voorstellen van de andere inschrijvers blijken er wel degelijk producten te bestaan die conform zijn en niet vervaardigd zijn uit PVC. Bijgevolg is het voorstel voor post 82 niet conform.

Indien de offerte voor meer dan 10% van de artikelen opgenomen in de inventaris geen conform voorstel bevat, wordt de offerte beschouwd als niet regelmatig en voor verder onderzoek uitgesloten. In totaal waren er 75 posten waarvoor er een artikel diende aangeboden te worden. Meer concreet wordt de offerte dus als niet regelmatig beschouwd van zodra er acht artikelen niet conform zijn. In totaal werden er door de inschrijver King Belgium NV negen artikelen aangeboden die niet conform zijn. Bijgevolg betreft dit een substantiële onregelmatigheid en blijft de offerte niet behouden voor verdere evaluatie."

3.6. Bij beslissing van 10 september 2020 keurt het college van burgemeester en schepenen van de stad Gent het gunningsverslag van 25 augustus 2020 goed en gunt de opdracht aan de bvba De Bruycker S. – Van Lierop M.

Dit is de bestreden beslissing.

Bij e-mailbericht en aangetekende brief van 21 september 2020 wordt de verzoekende partij van deze beslissing in kennis gesteld. Een kopie van de beslissing en van het gunningsverslag is bij de kennisgeving gevoegd.

#### *IV. Regelmatigheid van de rechtspleging*

4.1. Met een schrijven van 20 oktober 2020 heeft de verzoekende partij een “Verzoek tot lichting van de vertrouwelijkheid van stuk II.6 van Verwerende partij” ingediend, evenals een nieuw stuk neergelegd, bevattende “[e]en overzicht van de mogelijke microvezeldoeken die op heden door Verwerende partij worden gebruikt”.

#### *Wat het verzoek tot lichting van de vertrouwelijkheid van stuk II.6 betreft*

4.2. De verwerende partij heeft van een aantal door haar neergelegde stukken de vertrouwelijkheid uitdrukkelijk aangegeven en daarbij de redenen voor een vertrouwelijke behandeling uiteengezet. Het betreft de ingediende offertes alsook de briefwisseling die werd gevoerd tussen de inschrijvers en de aanbestedende overheid omtrent de inhoud van de offertes. Zij bevatten op het eerste gezicht bedrijfsvertrouwelijke gegevens waarvan het niet uitgesloten lijkt dat de openbaarmaking de wettige belangen van de inschrijvers zou kunnen schaden.

Het stuk, waarvan de verzoekende partij om de lichting van de vertrouwelijkheid verzoekt, betreft een e-mailbericht van de gekozen inschrijver aan de verwerende partij met technische informatie over de posten 43, 62, 66, 67 en 68 van de offerte van de gekozen inschrijver.

Het lijkt het niet raadzaam om in het kader van een procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid reeds de vertrouwelijkheid van dit stuk te lichten om de hiervoor aangehaalde redenen. De vertrouwelijke behandeling van dit stuk belet ook niet dat de Raad van State ervan kan kennisnemen en dit stuk in de beoordeling van de zaak betrekken. In de huidige stand van het geding lijken er geen redenen voorhanden om de vertrouwelijkheid van het betrokken stuk te lichten.



*Wat de neerlegging van een “nieuw stuk” betreft*

4.3. De verzoekende partij heeft naar aanleiding van het verweer in de nota van de verwerende partij met betrekking tot het tweede middel een “nieuw stuk” neergelegd, bevattende “[e]en overzicht van de mogelijke microvezeldoeken die op heden door Verwerende partij worden gebruikt”.

De ontvankelijkheid van de neerlegging van dit “nieuw stuk” en de daarbij ontwikkelde argumentatie vallen samen met het onderzoek en de beoordeling van het tweede middel.

*V. Schorsingsvoorwaarden*

5.1. Krachtens artikel 17, §§ 1 en 4, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid slechts worden besloten onder de dubbele voorwaarde dat minstens één ernstig middel wordt aangevoerd dat de nietigverklaring van de akte of het reglement *prima facie* kan verantwoorden en dat een uiterst dringende noodzakelijkheid voorhanden is die onverenigbaar is met de behandelingstermijn van de gewone vordering tot schorsing.

5.2. Te dezen is evenwel ook de wet van 17 juni 2013 ‘betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies’ van toepassing.

Krachtens artikel 15, eerste lid, van die wet kan de uitvoering worden geschorst van de thans bestreden beslissingen in aanwezigheid van een ernstig middel of een klaarblijkelijke onwettigheid.

Overeenkomstig artikel 15, tweede lid, echter wordt de vordering tot schorsing voor de Raad van State uitsluitend ingesteld volgens een procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid.

Er dient te dezen dan ook enkel nog te worden onderzocht of minstens één ernstig middel wordt aangevoerd, dan wel een klaarblijkelijke onwettigheid aanwezig is, die de nietigverklaring van de bestreden beslissingen kunnen verantwoorden.

## *VI. Onderzoek van de middelen*

6. De verzoekende partij voert twee middelen aan. Gelet op de draagwijdte van deze middelen is het passend eerst het tweede middel te beoordelen.

### *A. Tweede middel*

#### *Uiteenzetting van het middel*

7. In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, de artikelen 4 en 53 van de wet van 17 juni 2016 ‘inzake overheidsopdrachten’ (hierna: wet overheidsopdrachten 2016) en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het transparantiebeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel, het beginsel *patere legem quam ipse fecisti* en de materiële- en formelemotiveringsplicht.

#### *Eerste onderdeel*

8. In een eerste onderdeel voert de verzoekende partij aan dat de verwerende partij ten onrechte heeft besloten dat het product dat zij aanbood voor post 54 (microvezeldoek, rood, 40 x 40 cm) niet conform is omdat de aangeboden kleur zou afwijken van de gevraagde rode kleur voor sanitair. Volgens de verzoekende partij is de gevraagde rode kleur in de praktijk echter onbestaande en derhalve niet leverbaar. De producenten houden immers rekening met het productieproces en het gebruik van schoonmaakdoeken, waardoor deze niet worden geverfd in een “felrode” kleur. Op de markt zouden rode microvezeldoeken in werkelijkheid roze van kleur zijn, waarbij deze doeken een kleur hebben die binnen de roze schakering valt van donkerroze tot lichtroze. Uit het gunningsverslag blijkt ook dat geen enkele inschrijver voor post 54 een product

heeft kunnen aanbieden dat conform was. De door haar aangeboden roze microvezeldoek diende als gelijkwaardig te worden beschouwd aangezien de roze microvezeldoek eenzelfde doel bereikt als de rode microvezeldoek, namelijk eenvoudig te kunnen worden onderscheiden van de groene en blauwe microvezeldoeken.

### *Beoordeling*

9. Zoals hierna zal blijken is het eerste middelonderdeel niet ernstig.

10. Met betrekking tot de gevraagde microvezeldoek voor post 54 wordt in het bestek in de inventaris bepaald:

| Volgnr | Omschrijving aanbesteder         | Vereisten omtrent verpakkingseenheid, inhoud en afmetingen | Informatie omtrent huidig artikel                                | Type | Eenheid | Hoeveelheid |
|--------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------|
| 54     | Microvezeldoek, rood, 40 x 40 cm | Afmetingen: van 35 t.e.m. 45 cm                            | Microvezeldoek, polyester/polyamide, 40 x 40 cm, rood – per stuk | VH   | stuk    | 1.225       |

Voorts wordt onder de technische bepalingen van het bestek voor de schoonmaakproducten bepaald:

#### “Kleurcodering

De kleurcodering en het werken met concentraten zijn essentieel. De kleuren zijn bindend en dienen toegepast te worden op volgende artikelen: sproeiflacon, schoonmaakdoeken, doseerflessen, schuurspons, emmers. De volgende kleurcodering is van toepassing:

- rood: sanitair,
- blauw: interieur,
- groen: vloer.”

Uit het bestek blijkt aldus op het eerste gezicht dat de inschrijvers verplicht zijn een rode microvezeldoek aan te bieden. Er wordt daarbij niet voorzien dat kleurschakeringen tot lichtroze eveneens zijn toegelaten.

14. Het komt in de eerste plaats aan de aanbestedende overheid toe om de technische specificaties in het bestek vast te stellen en deze te interpreteren. Het is immers de aanbestedende overheid die haar behoeften bepaalt.

In overeenstemming met artikel 53, § 1, tweede lid, van de wet overheidsopdrachten 2016 dienen de technische specificaties verbonden en in verhouding te zijn met de waarde en de doelstelling van de opdracht. In dat verband wijst de verzoekende partij er zelf op dat het gebruikelijk is een kleurcode toe te passen bij schoonmaakdoeken om te vermijden dat ze voor het reinigen van sanitair, grondoppervlakten of meubilair tijdens een poetsbeurt met elkaar zouden worden verwisseld en dat de opgelegde internationale kleuren werden gekozen met het duidelijke doel om schoonmaakdoeken van elkaar te onderscheiden. De verwerende partij wijst er voorts in haar nota op dat het doel van de vereiste rode kleur voor de microvezeldoek (in plaats van de door de verzoekende partij aangeboden roze kleur) tevens is om de continuïteit te verzekeren voor haar diensten zodat zij kunnen blijven werken met de kleuren die zij op heden hanteren teneinde verwarring bij deze diensten te vermijden. Bijgevolg lijkt genoegzaam te kunnen worden aangenomen dat het vereiste van een rode kleur voor de betrokken microvezeldoeken in verhouding staat tot en verbonden is met de doelstelling van de opdracht.

15. Voorts verbiedt artikel 53, § 2, van dezelfde wet de aanbestedende overheid om voor een overheidsopdracht technische specificaties op te leggen die ongerechtvaardigde belemmeringen opwerpen voor de openstelling van overheidsopdrachten voor mededinging. De verzoekende partij betoogt weliswaar dat het in de praktijk onmogelijk zou zijn om een rode microvezeldoek aan te bieden omdat de op de markt zijnde “rode” microvezeldoeken in werkelijkheid “roze” microvezeldoeken zijn, waarbij de doeken een kleur hebben die binnen de roze schakering valt gaande van donkerroze tot lichtroze. Op het eerste gezicht blijkt echter uit de bijlage bij de brief die de verzoekende partij zelf op 30 september 2020 aan de verwerende partij stuurde dat er op de markt verscheidene microvezeldoeken in een rode kleur worden aangeboden die in ieder geval niet als lichtroze lijken te kunnen worden gekwalificeerd. Het gaat telkens om microvezeldoeken die zowel volgens hun productomschrijving in de betreffende catalogi als volgens de foto’s een rode kleur

hebben, terwijl de verzoekende partij in haar offerte een microvezeldoek aanbood die volgens de productomschrijving geen rode maar een roze kleur heeft (microvezeldoek Diamond roze) en volgens de afbeelding zelfs lichtroze van kleur is. De opmerking van de verzoekende partij dat producenten van schoonmaakdoeken geen “felrode” doeken zouden maken is alleszins niet relevant aangezien in het bestek een rode microvezeldoek wordt gevraagd zonder verdere specificaties omtrent de intensiteit van de rode kleur.

De verzoekende partij maakt dan ook niet aannemelijk dat de aanbestedende overheid, door voor de betrokken microvezeldoek te vereisen dat deze in een rode kleur wordt aangeboden, de mededinging zou hebben belemmerd. Dat te dezen geen van de inschrijvers voor de post 54 een rode microvezeldoek heeft aangeboden, doet niet anders besluiten.

16. Wat het door de verzoekende partij neergelegde “nieuw stuk” bevattende “[e]en overzicht van de mogelijke microvezeldoeken die op heden door Verwerende partij worden gebruikt” betreft, waaruit volgens haar “duidelijk [blijkt] dat deze doeken allen roze van kleur zijn, niettegenstaande dat de technische fiches vermelden dat ze ‘rood’ zijn”, en dat, indien de verwerende partij continuïteit in haar dagelijkse werking beoogt, de door haar aangeboden microvezeldoek volgens haar dezelfde kleur heeft als de microvezeldoek die momenteel door de diensten van de verwerende partij wordt gebruikt, wordt vastgesteld dat de verzoekende partij dit stuk reeds op het ogenblik van het instellen van de vordering kende, en aldus laattijdig aan het middelonderdeel een nieuwe invulling geeft die derhalve niet ontvankelijk is.

17. Gelet op de doelstelling van het vereiste, namelijk een duidelijke kleurcodering omwille van sanitaire redenen en omwille van continuïteit met betrekking tot deze kleuren om geen verwarring te veroorzaken bij de personeelsleden van de verwerende partij en gelet op het feit dat de door de verzoekende partij aangeboden lichtroze kleur in de technische specificaties van het product als roze werd omschreven en op zicht van de foto’s geenszins nog als een tint van rood lijkt te kunnen worden beschouwd, toont de verzoekende partij op het eerste gezicht niet aan dat de aanbestedende overheid te dezen de in het middel

aangehaalde bepalingen en beginselen heeft geschonden door de door de verzoekende partij voorgestelde microvezeldoek als niet conform te beschouwen.

18. Het eerste onderdeel is niet ernstig.

#### *Tweede onderdeel*

19. In een tweede onderdeel voert de verzoekende partij aan dat de verwerende partij ten onrechte oordeelde dat de vuilzakken die de verzoekende partij aanbood voor de posten 62, 64, 66 en 68 niet in overeenstemming zijn met de vereisten van het bestek omwille van hun kleur. De verzoekende partij is van mening dat noch het bestek, noch de inventaris bij het bestek een verplichting bevatten, laat staan op straffe van substantiële onregelmatigheid, volgens welke de kleuren van de vuilzakken exact dienen aan te sluiten bij de kleur die richtinggevend in de inventaris wordt vermeld. Dit in tegenstelling tot de kleurcodering die internationaal wordt gebruikt voor schoonmaakdoeken. Zij meent dat uit de bewoording van de productomschrijving in de inventaris niet kon worden afgeleid dat het aanbieden van een zwarte of een witte vuilzak verplicht was en dat het aanbieden van een gelijkwaardige grijze of transparante vuilzak automatisch zou leiden tot niet-conformiteit voor de posten 62, 64, 66 en 68. De verzoekende partij ging er dan ook te goeder trouw van uit dat de huidige gebruikte kleur de voorkeur genoot maar geenszins verplicht diende te worden aangeboden. Volgens de verzoekende partij ging het om “wenselijke eisen” zodat het niet beantwoorden daaraan geen invloed mocht hebben op de regelmatigheid van de offerte. Zij verwijst daarbij naar de overwegingen in het arrest van de Raad van State nr. 243.024 van 23 november 2018.

Voorts meent zij dat de door haar aangeboden grijze vuilzak gelijkwaardig is aan de gevraagde zwarte vuilzak aangezien het doel van de zwarte kleur wordt bereikt, namelijk te onderscheiden zijn van de blauwe, witte, gele en groene vuilzakken die courant worden gebruikt in de professionele schoonmaaksector. In tegenstelling tot het gebruik van bijvoorbeeld blauwe vuilzakken is er geen expliciet gebruik toegeschreven aan zwarte dan wel aan grijze vuilzakken. Eenzelfde redenering geldt volgens de verzoekende partij voor de witte dan wel transparante vuilzakken. Uit de foto opgenomen in het

verzoekschrift blijkt volgens de verzoekende partij dat de door haar aangeboden grijze vuilzak een zeer donkergrijze vuilzak betreft die nauwelijks te onderscheiden is van een zwarte. Hetzelfde geldt voor de transparante witte vuilzak. De verwerende partij heeft de hiervoor aangehaalde bepalingen en beginselen geschonden door geen stalen op te vragen of door de verzoekende partij niet te bevragen. Ook werd het gelijkheidsbeginsel geschonden aangezien de mogelijkheid bestaat dat de door de gekozen inschrijver aangeboden “zwarte” of “witte” vuilzakken in werkelijkheid ook “grijs” en niet “melkwit transparant” zullen zijn.

Daarnaast heeft de verwerende partij volgens de verzoekende partij ook de materiële- en de formelemotiveringsplicht geschonden door in het gunningsverslag niet te verduidelijken waarom een grijze vuilzak niet gelijkwaardig is aan een zwarte en een melkwhite transparante niet aan een witte.

Ten slotte merkt de verzoekende partij nog op dat vanaf 1 januari 2021 het in Vlaanderen verboden zal zijn om vuilzakken te gebruiken die niet worden geproduceerd op basis van gerecycleerde kunststoffen. Zij leidt hieruit af dat er vanaf dat ogenblik geen zwarte of witte vuilzakken meer kunnen worden aangeboden aangezien vuilzakken, gelet op het verplichte percentage van gerecycleerde kunststoffen, met een volledig corresponderende en homogene kleur niet meer te produceren zullen zijn. Ook om deze reden zou de aanbestedende overheid een vuilzak met een donkergrijze kleur in plaats van zwart niet als niet-conform mogen beoordelen, evenmin als zij een transparante melkwhite vuilzak in plaats van een witte vuilzak nog als niet-conform mocht beoordelen.

### *Beoordeling*

21. De verzoekende partij houdt op het eerste gezicht ten onrechte voor dat uit het bestek geenszins zou blijken dat de kleuren van de voorgestelde vuilzakken dienden aan te sluiten bij de kleuren vermeld in de inventaris.

In de inventaris wordt in de kolom met als titel “Omschrijving aanbesteder” voor de betrokken posten vermeld :

| Volgnr | Omschrijving aanbesteder                         | Vereisten omtrent verpakkingseenheid, inhoud en afmetingen | Informatie omtrent huidig artikel                    | Type | Eenheid | Hoeveelheid |
|--------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|---------|-------------|
| 62     | Vuilzak, 44 x 60 cm, min 10 µm, wit              | Afmetingen mogen max. 20 % afwijken                        | Vuilzak, wit, 44 x 60 cm, 10 µm, rol 50 zakken       | VH   | zak     | 139.911     |
| 64     | Vuilzak, 70 x 110 cm, min 25 µm, wit             | Afmetingen mogen max. 20 % afwijken                        | Vuilzak, wit, 70 x 110 cm, 25 µm, 10 x rol 20 zakken | VH   | zak     | 1.489.200   |
| 66     | Vuilzak, 80 x 110 cm, min 30 µm, zwart           | Afmetingen mogen max. 20 % afwijken                        | Vuilzak, zwart, 80 x 110 cm, 30 µm, rol 25 zakken    | VH   | zak     | 325.550     |
| 68     | Vuilzak, pedaalemmer, 60 x 60 cm, min 15 µm, wit | Afmetingen mogen max. 20 % afwijken                        | Vuilzak, wit, 60 x 60 cm, 15 µm, rol 50 zakken       | VH   | zak     | 664.700     |

De kleuren wit, respectievelijk zwart, worden aldus duidelijk vermeld bij de productomschrijving van de betrokken posten. Dat deze kleuren niet op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven, doet niets af aan hun karakter van technische vereiste waaraan het voorgestelde product bijgevolg in beginsel dient te voldoen.

22. Het betoog van de verzoekende partij dat het slechts om “wenselijke eisen” zou gaan, lijkt geen steun te vinden in het bestek. Immers, in tegenstelling tot de feiten die ten grondslag lagen aan het arrest waar de verzoekende partij naar verwijst, wordt de witte dan wel de zwarte kleur te dezen in het bestek geenszins aangemerkt als een meerwaarde op grond waarvan de offerte van de inschrijver beter kan worden gewaardeerd. Dit zou dan immers moeten blijken uit de omschrijving van de gunningscriteria. Te dezen zijn er slechts twee gunningscriteria, namelijk de prijs en de duurzaamheid. Dat laatste criterium bestaat uit een subcriterium “project” waarbij een duurzaamheidsproject moet worden voorgesteld en een subcriterium “sociale economie” waarbij moet worden aangetoond welke maatregelen worden genomen rond sociale economie. Geen van de gunningscriteria heeft aldus betrekking op een beoordeling van de kleur van de vuilzakken.

Voorts komt het zoals reeds vermeld aan de aanbestedende overheid toe om haar behoeften te bepalen en dus de vereisten te bepalen waaraan



de te leveren producten moeten voldoen. De kleur van de vuilzakken lijkt op het eerste gezicht een vereiste die verbonden en in verhouding is met de waarde en de doelstelling van de opdracht. Ook met betrekking tot de vereiste kleur van de vuilzakken wijst de verwerende partij op de continuïteit voor haar diensten om met dezelfde kleuren te kunnen blijven werken.

Wanneer bijgevolg in het bestek gevraagd wordt om een witte dan wel een zwarte vuilzak te leveren, lijkt de verwerende partij te kunnen worden bijgevalen in haar stelling dat een transparante of grijze vuilzak niet aan die vereiste voldoet. Dit geldt des te meer aangezien voor de gevraagde vuilzak in post 65 in de inventaris bij het bestek bij de omschrijving van het product door de aanbesteder wel uitdrukkelijk wordt aangegeven “grijs of zwart”. Het laat zich dan ook aanzien dat wanneer bij post 66 bij de productomschrijving van de vuilzak enkel de kleur “zwart” wordt vermeld, er in beginsel een zwarte vuilzak moet worden geleverd en geen grijze. Hetzelfde geldt voor de eis om een witte vuilzak te leveren. In tegenstelling tot wat de verzoekende partij voorhoudt, is een transparante vuilzak niet noodzakelijkerwijze te beschouwen als een witte vuilzak. Niet alleen is de eigenschap “transparant” niet hetzelfde als de kleur wit, ook zal de inhoud van de vuilzak die de verzoekende partij voorstelde zichtbaar zijn, terwijl dit bij een witte vuilzak in beginsel niet zo is. Bovendien, in de mate dat de verzoekende partij twijfels had bij de mogelijkheid om met verwante tinten van kleur in te schrijven, had zij de aanbestedende overheid hierover kunnen bevragen alvorens een offerte in te dienen.

Thans merkt de verzoekende partij in haar verzoekschrift op dat de door haar aangeboden grijze vuilzak eigenlijk zeer donkergrijs is en nauwelijks te onderscheiden van een zwarte vuilzak. Het kwam haar als zorgvuldige inschrijver echter toe om in haar offerte daarop te wijzen, eventueel ondersteund door het toevoegen van een staal van de betreffende vuilzakken. In de inventaris van haar offerte heeft zij de kleur van de vuilzak die zij aanbood voor post 66 immers zelf omschreven als “grijs” en niet als “zwart” zonder verdere toelichting in haar offerte. Evenzo heeft de verzoekende partij de kleur van de vuilzak die ze aanbood voor de posten 62, 64 en 68 omschreven als “transparant” en dus zelfs niet als “melkwit” zoals ze thans in haar verzoekschrift betoogt. Er was in de offerte dan ook geen enkel element aanwezig op grond waarvan de verwerende partij had

dienen aan te nemen dat het ging om kleuren die voldoen aan de gevraagde zwarte en witte kleur.

23. In de mate dat de verzoekende partij voorts aanvoert dat de gelijkheid onder de inschrijvers zou zijn geschonden doordat de verwerende partij geen stalen opvroeg, zodat ook niet zeker is of de gekozen inschrijver met de exact gevraagde kleuren inschreef, moet worden vastgesteld dat het bestek geenszins bepaalt dat er stalen dienden te worden bezorgd. Voorts is er op het eerste gezicht geen enkele reden om aan te nemen dat de gekozen inschrijver niet zou hebben ingeschreven met de gevraagde kleur vuilzakken. In de inventaris heeft deze inschrijver telkens de kleur vermeld van het aangeboden product en deze blijkt zwart te zijn voor post 66 en wit voor de posten 62, 64 en 68.

24. Aangezien volgens de omschrijving van het product in de inventaris voor de posten 62, 64 en 68 telkens een witte vuilzak diende te worden voorgesteld en voor post 66 een zwarte vuilzak, kon de verwerende partij om te voldoen aan de motiveringsplicht volstaan met de vaststelling dat het in de offerte van de verzoekende partij voorgestelde product voor de betrokken posten niet conform was nu geen witte maar een transparante vuilzak werd voorgesteld en geen zwarte maar een grijze.

25. Ten aanzien van de opmerking van de verzoekende partij dat vanaf 1 januari 2021 het in Vlaanderen verboden zal zijn om vuilzakken te gebruiken die niet worden geproduceerd op basis van gerecycleerde kunststoffen zodat het niet meer mogelijk zou zijn om zwarte of witte vuilzakken aan te bieden, moet in de eerste plaats worden vastgesteld dat deze bewering op generlei wijze wordt gestaafd. De verzoekende partij voert evenmin aan dat de besteksvereiste “zwarte” en “witte” vuilzakken onrechtmatig zou zijn. Het argument lijkt dan ook niet dienstig om een onwettigheid van de bestreden beslissing aan te tonen.

26. Het onderdeel is niet ernstig.

### *Derde onderdeel*

27. In dit onderdeel voert de verzoekende partij aan dat de verwerende partij ten onrechte heeft besloten dat het product dat zij aanbood voor post 41 (afwasborstel, kunststof) en post 82 (toiletborstel, kunststof, met randreiniger en houder) niet conform is terwijl noch het bestek, noch de inventaris bij het bestek een verplichting bevat op straffe van substantiële onregelmatigheid volgens dewelke de aangeboden producten volledig vrij dienen te zijn van PVC. Het bestek geeft volgens de verzoekende partij enkel een voorkeur aan voor producten die geen PVC bevatten. Het volledig vrij zijn van PVC betreft slechts een “wenselijke eis” zodat het niet beantwoorden daaraan geen invloed mag hebben op de regelmatigheid van de offerte. De verzoekende partij zou dan ook conform het bestek hebben gehandeld door producten aan te bieden die deels zijn vervaardigd uit PVC.

Door in het gunningsverslag niet toe te lichten waarom de aangeboden borstels die deels bestaan uit PVC niet als gelijkwaardig kunnen worden geacht, heeft de verwerende partij dan ook het materiële- en het formelemotiveringsbeginsel geschonden.

### *Beoordeling*

28. In de technische bepalingen van het bestek wordt met betrekking tot de te leveren schoonmaakmiddelen bepaald:

“Kunststof

Gezien de ecologische impact ervan, wordt ernaar gestreefd dat geen enkel product polyvinylchloride (PVC) bevat. Voor dergelijke producten wordt vereist (indien beschikbaar) dat deze vervaardigd worden uit polypropyleen (PP). Indien dit voor een bepaald product niet verkrijgbaar is op de markt, wordt de voorkeur gegeven aan gerecycleerd materiaal.”

29. Uit de formulering in de technische bepalingen van het bestek waarin “vereist” wordt dat aangeboden producten vervaardigd worden uit polypropyleen indien beschikbaar, en dat enkel wanneer “dit voor een bepaald product niet verkrijgbaar is”, de voorkeur wordt gegeven aan gerecycleerd

materiaal, blijkt op het eerste gezicht voldoende duidelijk dat de producten in kunststof die de inschrijvers aanbieden in hun offerte verplicht vervaardigd moeten zijn uit polypropyleen, tenzij wanneer dit niet verkrijgbaar is op de markt. Er blijkt in het bestek geen sprake van een gedeeltelijke vervaardiging uit polypropyleen. Opnieuw kan hier worden vastgesteld dat het materiaal waaruit de aangeboden producten zijn vervaardigd niet betrokken wordt in de omschrijving van de gunningscriteria en geen aanleiding gaf tot een betere waardering van de offertes. Het ging dus niet om een wenselijke eis zoals de verzoekende partij ten onrechte lijkt voor te houden.

Voorts betwist de verzoekende partij niet dat er voor de posten 41 en 82 op de markt producten beschikbaar zijn die volledig vervaardigd zijn uit polypropyleen. Dit wordt ook bevestigd door de offertes van de andere inschrijvers.

Gelet op het voorgaande lijkt de verwerende partij in overeenstemming met de bepalingen van het bestek op het eerste gezicht te hebben mogen besluiten dat de producten die de verzoekende partij aanbood en die gedeeltelijk uit PVC werden vervaardigd niet in overeenstemming zijn met het gevraagde in het bestek zodat het aanbod voor de posten 41 en 82 niet conform is.

30. Door in het gunningsverslag vast te stellen dat de door de verzoekende partij aangeboden producten deels uit PVC werden vervaardigd en vervolgens de duidelijke tekst van het bestek ter zake te parafraseren, gevolgd door de vaststelling dat uit de voorstellen van de andere inschrijvers bleek dat er wel degelijk producten op de markt zijn vrij van PVC, zodat het voorstel voor deze betrokken posten niet conform is, lijkt de bestreden beslissing in feite en in rechte afdoende gemotiveerd.

31. Het derde onderdeel is niet ernstig.

32. Het tweede middel is in zijn geheel niet ernstig.

33. Aangezien geen van de middelonderdelen ernstig werd bevonden, kan in de huidige stand van het geding worden aangenomen dat in de

bestreden beslissing terecht werd geoordeeld dat de offerte van de verzoekende partij voor meer dan 10 % van de posten een niet-conform voorstel bevatte. Bijgevolg werd op het eerste gezicht eveneens en in overeenstemming met de bepalingen van het bestek vastgesteld dat de offerte van de verzoekende partij niet voor nadere beoordeling in aanmerking kwam en de verzoekende partij bijgevolg terecht werd geweerd als een onregelmatige inschrijver.

Uit de bestreden beslissing blijkt evenwel dat de gekozen inschrijver de enige regelmatige inschrijver is. In zoverre de verzoekende partij in haar eerste middel de deugdelijkheid van het gevoerde regelmatigheidsonderzoek met betrekking tot de offerte van de gekozen inschrijver bekritiseert, heeft zij, ook als op het eerste gezicht onregelmatige inschrijver, belang bij dit middel.

#### *B. Eerste middel*

##### *Uiteenzetting van het middel*

34. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, de artikelen 4, 66, § 3, eerste lid, en 81, § 1, van de wet overheidsopdrachten 2016, de artikelen 54, § 2, eerste lid, 76, §§ 1 en 3, en 83 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 ‘plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren’ en van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het transparantiebeginsel, het beginsel *patere legem quam ipse fecisti*, het zorgvuldigheidsbeginsel, het onpartijdigheidsbeginsel, het mededingingsbeginsel en de materiële- en formelemotiveringsplicht.

De verzoekende partij voert in dit middel aan dat de aangehaalde bepalingen en beginselen werden geschonden doordat aan de gekozen inschrijver de mogelijkheid werd geboden om, na het uiterste moment van indiening van de offertes, essentiële elementen van zijn offerte te wijzigen. Hoewel artikel 66, § 3, eerste lid, van de wet overheidsopdrachten 2016 aan de aanbestedende overheid de mogelijkheid geeft om aan de inschrijver te vragen onvolledige of onjuiste informatie of documentatie aan te vullen, te verduidelijken of te vervolledigen, moet een dergelijk verzoek gebeuren met inachtneming van het gelijkheidsbeginsel en mag dit geen aanleiding geven tot een wijziging van de

offerte. Door aan de gekozen inschrijver op 16 juli 2020 nog te vragen om de posten 43, 62, 66, 67 en 68 in zijn inventaris aan te vullen terwijl de overige inschrijvers deze mogelijkheid niet kregen, heeft de verwerende partij het gelijkheidsbeginsel geschonden.

Het aanvullen van de artikelnummers voor de posten 43, 62, 66, 67 en 68 door de gekozen inschrijver gaat volgens de verzoekende partij verder dan een verzoek tot het overmaken van bijkomende informatie zoals bedoeld in artikel 66, § 3, eerste lid, van de voormelde wet. De mogelijkheid voor de gekozen inschrijver om deze posten aan te vullen, heeft een daadwerkelijke impact gehad op de conformverklaring van die posten en het regelmatig bevinden van de offerte. Het gaat dan ook om het wijzigen van essentiële elementen. De verwerende partij had de offerte van de gekozen inschrijver moeten weren als onregelmatig omdat deze zijn inventaris niet correct had ingevuld voor de posten 43, 62, 66, 67 en 68. Hierdoor kwam immers de beoordeling van de offerte en de vergelijking met de offertes van de andere inschrijvers in het gedrang.

De verzoekende partij hekelt voorts het feit dat in de bestreden beslissing niet wordt gemotiveerd waarom de offerte van de gekozen inschrijver slechts vijf niet conforme posten bevat terwijl deze offerte nochtans ook voor de posten 43, 62, 66, 67 en 68 in de inventaris geen artikelnummer vermeldde, zodat het niet mogelijk was de offerte met betrekking tot die posten te beoordelen. De verwerende partij had de offerte voor deze posten eveneens niet-conform moeten bevinden zodat de offerte van de gekozen inschrijver in totaal 10 niet-conforme posten bevatte en bijgevolg substantieel onregelmatig had moeten worden verklaard.

Ten slotte meent de verzoekende partij dat uit het gunningsverslag blijkt dat de verwerende partij geen zorgvuldig nazicht deed van de offerte van de gekozen inschrijver. Zo wordt er voor volgnummer 5 in “Bijlage A: Korting catalogus” voor de beoordeling van het tweede prijscriterium een groene dweil gevraagd. Voor de gekozen inschrijver wordt echter in de beoordeling van de prijs een blauwe dweil betrokken, zonder enige motivering waarom een blauwe dweil gelijkwaardig zou zijn aan een groene dweil.

### *Beoordeling*

35. In de inventaris bij de offerte dienden de inschrijvers naast de informatie omtrent de omschrijving van het aangeboden product, de verpakkingshoeveelheid, het merk en de eenheidsprijs ook het artikelnummer van het product in de catalogus van de leverancier te vermelden. Met dat artikelnummer kon de verwerende partij het voorgestelde product terugvinden in de catalogus van de leverancier om zo de technische specificaties van het product te vergelijken met de technische vereisten van het bestek.

In het gunningsverslag dat bij de bestreden beslissing werd gevoegd, wordt met betrekking tot het regelmatigheidsonderzoek van de offerte van de gekozen inschrijver onder meer vermeld:

“(6) De inschrijver De Bruycker S. – Van Lierop M. BVBA heeft voor de posten 43, 62, 66, 67 en 68 uit de inventaris geen artikelnummers opgenomen in de inventaris, waardoor de aanbesteder niet kon controleren of de voorgestelde artikelen voldoen aan de gestelde vereisten. Op 16/07/2020 heeft de aanbesteder hieromtrent meer informatie gevraagd. Op 31/07/2020 heeft de inschrijver per e-mail de nodige informatie en correcte documenten bezorgd. Dit betreft geen substantiële onregelmatigheid.”

36. In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat uit nazicht van de elektronische catalogi van de inschrijvers op het eerste gezicht blijkt dat de technische specificaties die bij de producten in de catalogus van de inschrijvers worden vermeld, dezelfde informatie blijken te bevatten als de technische specificaties die zijn vermeld in de inventaris bij de offertes.

Daarnaast blijkt uit de offerte van de gekozen inschrijver, die als vertrouwelijk stuk in het administratief dossier werd opgenomen en waarvan de Raad van State kennis mag nemen, dat in de inventaris van zijn offerte voor de betrokken posten een volledige beschrijving heeft opgenomen van het voorgestelde artikel met vermelding van de afmetingen, kleur, materiaal, dikte, de verpakkingseenheid, het merk, alsook de prijs. Enkel het artikelnummer in de catalogus van de gekozen inschrijver werd niet vermeld, maar in de plaats daarvan werd aangegeven “nog toe te kennen”. De betreffende producten hadden bijgevolg

nog geen artikelnummer in de catalogus van de gekozen inschrijver en konden door de verwerende partij dan ook nog niet worden teruggevonden in de catalogus.

37. In de eerste plaats wordt vastgesteld dat de verzoekende partij geen bepaling uit het bestek aanduidt op grond waarvan het niet vermelden van het artikelnummer in de inventaris leidt tot de formele nietigheid van de offerte. Het enkele gegeven dat de inventaris integraal deel uitmaakt van de offerte leidt op het eerste gezicht niet tot dat besluit. Evenmin duidt de verzoekende partij een besteksbepaling aan op grond waarvan de inschrijver verplicht was, laat staan op straffe van nietigheid van de offerte, om bij zijn offerte technische fiches te voegen omtrent de aangeboden producten.

Voorts wordt op het eerste gezicht vastgesteld dat de aanvullende informatie die de gekozen inschrijver na opening van de offertes heeft bezorgd aan de verwerende partij, en die blijkt uit het e-mailbericht van de gekozen inschrijver van 31 juli 2020 waarop de Raad van State vermag acht te slaan, slechts betrekking heeft op producten die reeds waren opgenomen in de inventaris, maar die nog geen artikelnummer hadden gekregen in de catalogus van de gekozen inschrijver. Het lijkt niet zo te zijn dat deze inschrijver nieuwe producten heeft toegevoegd aan zijn inventaris dan wel reeds in de offerte opgenomen producten zou hebben gewijzigd. De voorgestelde producten werden reeds duidelijk geïdentificeerd in de inventaris van de offerte aan de hand van hun verpakkingseenheid, inhoud, afmetingen, materiaal, dikte, kleur, (merk) en prijs. In die zin lijken er geen essentiële wijzigingen aangebracht te zijn aan de offerte van de gekozen inschrijver door het later toevoegen van de technische informatie. De technische informatie in het e-mailbericht van 31 juli 2020 blijkt ook overeen te stemmen met de technische informatie die reeds werd vermeld in de inventaris. Geenszins lijkt aan de gekozen inschrijver de mogelijkheid te zijn geboden om zijn offerte nog te wijzigen.

Aangezien geen wijziging lijkt te zijn aangebracht aan de voorgestelde producten zelf, lijkt er ook geen wijziging te zijn aangebracht aan de al dan niet conformiteit van deze producten met de vereisten van het bestek. Het enige wat blijkt te zijn aangevuld is de technische informatie om de conformiteit van de producten te kunnen beoordelen. Zoals gezegd toont de verzoekende partij



niet aan dat het niet vermelden van het artikelnummer van de producten of het niet toevoegen van de daaraan verbonden technische informatie bij de offerte op zich op grond van de besteksbepalingen een onregelmatigheid uitmaakt. Zo valt op te merken dat volgens de bewoordingen van de inventaris voor sommige posten bij de offerte verplicht een technische fiche of een kopie van het etiket diende te worden toegevoegd. Voor de posten 43, 62, 66, 67 en 68 was dit echter niet het geval. Ook op dit punt werd bijgevolg aan de gekozen inschrijver niet de gelegenheid geboden om een (substantieel) onregelmatige offerte te wijzigen of te regulariseren. Bijgevolg lijkt het opvragen van de technische informatie omtrent de voorgestelde producten die nog geen artikelnummer hadden in de catalogus van de gekozen inschrijver zich in te passen in de mogelijkheid die artikel 66, § 3, eerste lid, van de wet overheidsopdrachten 2016 laat aan de aanbestedende overheid om de inschrijver te verzoeken om ontbrekende documenten in zijn offerte te vervolledigen, zonder dat daarbij een wijziging wordt aangebracht aan essentiële elementen van de offerte. Evenmin lijkt daarbij het gelijkheidsbeginsel te zijn geschonden, nu de verzoekende partij niet aantoont dat zij zich in eenzelfde situatie bevond terwijl aan haar niet de mogelijkheid zou zijn geboden om aanvullende technische gegevens te bezorgen, zonder de inhoud van haar offerte te wijzigen. Ook aan andere inschrijvers werd trouwens de mogelijkheid geboden om aanvullende technische gegevens te bezorgen, zoals blijkt uit het gunningsverslag

38. Ter terechtzitting voert de verzoekende partij nog aan dat de technische specificaties die door de gekozen inschrijver bij e-mailbericht van 31 juli 2020 aan de verwerende partij werden overgemaakt met betrekking tot de posten 43, 62, 66, 67 en 68 niet kunnen volstaan om de conformiteit van de producten te beoordelen, aangezien deze conformiteit slechts afdoende kan worden beoordeeld indien de aangeboden producten ook effectief bestaan, en uit het bij de nota gevoegde uittreksel uit het stuk II.6 blijkt dat de aangeboden producten voor de posten 43, 62, 66, 67 en 68 nieuw zijn en nog niet in het gamma van de gekozen inschrijver zitten, en voor de posten 62, 66, 67 en 68 de aangeboden producten zelf nog op maat moeten worden gemaakt. De aan de fabrikant aangeleverde “technische specificaties” stemmen daarom niet automatisch overeen met de effectieve technische kenmerken van de finaal geproduceerde producten.

Ook in deze stelling wordt de verzoekende partij niet bijgevalen. Het bestek vereist op het eerste gezicht niet dat van de aangeboden producten op het ogenblik van het indienen van de offerte een staal moet worden bijgevoegd ter beoordeling van de technische conformiteit van de aangeboden producten. De controle van de technische conformiteit van de producten gebeurt uitsluitend aan de hand van de technische specificaties zoals vermeld door de leverancier. Dat het aangeboden product al dan niet reeds bestaat op het ogenblik van de indiening en de beoordeling van de offertes lijkt in dat opzicht niet essentieel voor de beoordeling van de conformiteit van de aangeboden producten. De conformiteit van het uiteindelijk geleverde product met de vereisten uit het bestek zal in ieder geval ook gecontroleerd kunnen worden bij de uitvoering van de opdracht.

39. Aangezien er geen sprake lijkt te zijn van een onregelmatigheid of niet-conformiteit met betrekking tot de voormelde posten, diende de verwerende partij ook niet bijzonder te motiveren waarom zij de offerte voor de betreffende posten conform beschouwde. Zij kon volstaan met de overweging dat de inschrijver met een e-mailbericht de nodige informatie en correcte documenten had bezorgd om na te gaan of de aangeboden producten voldoen aan de gestelde vereisten.

40. Ten slotte blijkt uit de beoordeling van het prijs criterium voor de “Korting catalogus” evenmin een onzorgvuldig optreden van de aanbestedende overheid. Het bestek bepaalt met betrekking tot dit prijs criterium dat de inschrijver een kortingspercentage dient op te nemen in zijn offerte op alle bijkomende artikelen die besteld zouden worden naast de artikelen die reeds opgenomen waren in de inventaris. Voor de beoordeling van dit criterium legde de verwerende partij vooraf een lijst vast die niet aan de inschrijvers werd meegedeeld van 50 artikelen die courant werden afgenomen. De totale nettoprijs van de artikelen uit die lijst die in het aanbod van elke inschrijver voorkwamen, zou worden vergeleken. Bij het gunningsverslag werd vervolgens de tabel gevoegd met de 50 artikelen die voor dit gunningscriterium in aanmerking werden genomen. Zo werd als vijfde artikel een dweil, microvezel, polyester/polyamide, min. 340 g/m<sup>2</sup>, groen vermeld. Zoals de verzoekende partij terecht opmerkt, werd bij de beoordeling voor de gekozen inschrijver vervolgens een artikelnummer uit de catalogus weergegeven dat

betrekking blijkt te hebben op een blauwe dweil in plaats van een groene. De verwerende partij wijst er in haar nota op dat het ging om een materiële vergissing van harentwege en dat artikelnummer DWSALGR had moeten worden vermeld, dat wel degelijk betrekking heeft op een groene dweil, in plaats van artikelnummer DWWEMICBL. Dit artikel had een identieke prijs. De verwerende partij merkt op dat aangezien geen van de andere inschrijvers een regelmatige offerte had ingediend, de kortingspercentages van de inschrijvers voor dit gunningscriterium uiteindelijk niet meer werden vergeleken, waardoor deze materiële fout niet aan het licht kwam. Met de verwerende partij lijkt te kunnen worden aangenomen dat mochten de kortingspercentages wel zijn vergeleken, deze administratieve fout zou zijn opgemerkt, minstens lijkt dit bezwaarlijk als een bewijs van onzorgvuldigheid te moeten worden beschouwd waarmee het ganse beoordelingsproces zou zijn behept.

De verzoekende partij lijkt overigens geen belang te hebben bij deze kritiek zoals de verwerende partij opmerkt aangezien de gekozen inschrijver als enige regelmatige inschrijver hoe dan ook het maximum van de punten verkreeg op dit criterium. Bovendien gaat het weliswaar over een ander artikelnummer doch aan dezelfde prijs, zodat de score geenszins zou zijn gewijzigd.

41. Het eerste middel is niet ernstig.

#### *VII. Besluit*

42. Geen van beide middelen is ernstig gebleken. De vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid dient dan ook te worden verworpen.

### **BESLISSING**

#### **1. De Raad van State verwerpt de vordering.**

**2. De verzoekende partij wordt verwezen in de kosten van de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, begroot op een rolrecht van 200 euro, een bijdrage van 20 euro, en een rechtsplegingsvergoeding van 700 euro, die verschuldigd is aan de verwerende partij.**

Dit arrest is uitgesproken te Brussel, in openbare terechtzitting van drie november tweeduizend twintig, door de Raad van State, XIIe kamer, samengesteld uit:

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Johan Bovin,    | staatsraad, waarnemend voorzitter, |
| bijgestaan door |                                    |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Greta Scheveneels, | griffier. |
|--------------------|-----------|

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <b>De griffier</b> | <b>De voorzitter</b> |
|--------------------|----------------------|

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Greta Scheveneels</b> | <b>Johan Bovin</b> |
|--------------------------|--------------------|